

RECURSO CÍVEL Nº 5069979-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: FELIPE RAMALHO DA SILVA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IRPF SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). SENTENÇA PROCEDENTE. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E RECONHECIMENTO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. LEI Nº 13.467/17 DISPÕE SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO SOB A RUBRICA "ADICIONAL INTERVALO (32,5%)". PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA) E TEMA 306 TNU. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE Nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA RE E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO. Sem custas. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5069979-52.2024.4.02.5101

510014582789 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069979-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: FELIPE RAMALHO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de recurso inominado tempestivo interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido de exclusão dos valores pagos a título de HRA (hora repouso alimentação) sob a rubrica "ADICIONAL INTERVALO (32,5%)", da base de cálculo do imposto de renda e a condenação da ré na restituição dos valores indevidamente cobrados.

Em suas razões, reitera todos os seus argumentos de contestação.

VOTO

No que toca à prescrição aplicável ao caso concreto, observe-se a prescrição quinquenal.

A temática em exame foi apreciada por esta 8ª Turma Recursal em sessão realizada em 18/08/2020 (Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ, de relatoria do Dr. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA). Segue trecho do julgamento:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA SOBRE ELA, CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

A CLT prevê no artigo 71 que quando o período para repouso e alimentação não for concedido, a empresa tem de remunerar o funcionário pelo tempo correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

A problemática reside em saber qual a natureza dos pagamentos: se esta é indenizatória ou remuneratória. No primeiro caso, não há tributação, já que não se trata de salário. No segundo caso, deverá haver tributação.

Pois bem, quanto ao tema o STJ já havia firmado entendimento de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídos tem sua natureza salarial e incidem sobre elas a tributação, nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017.

Assim, não possuindo natureza indenizatória, mas salarial, é possível a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda, em princípio.

Quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.

CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017.

(EREsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020)

Todavia, como ressaltado no julgado acima, a Lei nº 13.467/2017, no artigo 71, § 4º trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)** **(Vigência)**

§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e

afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. **(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)**

Assim, não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17.

No entanto, a par da modificação introduzida pela legislação trabalhista entende-se que a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, configurando retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991.

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Tema 20. RE 565.160. Salário-maternidade. Salário-paternidade. Férias usufruídas. Horas extras. Adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade. Atestados médicos/faltas justificadas. Auxílio-alimentação (em pecúnia). Repouso semanal remunerado e feriados. Intrajornada. Décimo terceiro salário. Salário família. Abono de férias. Auxílio educação. Auxílio casamento e auxílio funeral. Auxílio-creche. Abono de faltas. Abono assiduidade. Adicional de transferência. Férias usufruídas. Adicional constitucional sobre férias gozadas. Primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Aviso prévio indenizado. [...] 4. **Incide contribuição previdenciária sobre salário maternidade, salário-paternidade, férias usufruídas, horas extras, adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade, atestados médicos/faltas justificadas, auxílio-alimentação (em pecúnia), repouso semanal remunerado e feriados, intrajornada, décimo terceiro salário, abono de faltas, adicional de transferência. (TRF4 5003384-65.2014.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 19/12/2017)**

Com efeito, a referida rubrica será incorporada aos proventos de aposentadoria, já que faz parte do seu cálculo, mesmo na legislação atual."

No mesmo sentido é o Tema 306 da TNU:

Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como **Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)**, em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), **não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.**

Uma vez que a sentença foi proferida em harmonia com o entendimento acima referido, o recurso deve ser improvido.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA RE E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.